



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקחת י. ענתבי- שרון

תיק מס': 146/10

התובעת:

נציגות הבית המשותף

רחוב מעגלי יבנה 5, ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד ב. מאירי
רחוב כורש 6, ירושלים

ג ג ד -

הנתבעים:

1. אנרי קטורזה

2. שושנה קטורזה

ע"י ב"כ עו"ד ע. חזיזה
רחוב יפו 216, "שערי העיר", ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה ב בקשה למתן צו עשה ל סילוק יד מהרכוש המשותף , לרבות הסרת בנייה וחפצים ממנו, השבת מצב לקדמותו, החזרת רכוש, ומסירת דו"חות דפי חשבון וספרי נציגות לתובעת.

תביעה זו הוגשה ביום 1.8.10 ונשמעה בפני כבוד המפקח הבכיר (בדימוס) מר פנחס לוי. כבוד המפקח לוי פרש מתפקידו לאחר שמיעת מסכת הראיות בשלמותה ואולם טרם שהיה סיפק בידו ליתן את פסק הדין.

מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**"), הועבר תיק זה לטיפול בנובמבר 2012, לאחר פרישתו של כבוד המפקח ל וי ובתום הגשת סיכומי הצדדים בכתב . טרם מתן פסק הדין ערכתי ביקור במקום, בנוכחות באי כוח הצדדים . פסק דין זה ניתן , לפיכך, על יסוד החומר הקיים בתיק ו נוכח התרשמותי מהביקור שערכתי במקום.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

העובדות

1. עסקינן בבית משותף המצוי ברחוב מעגלי יבנה 5 בירושלים והידוע כ גוש 30173 חלקה 149 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). כעולה מנסח הרישום, הבית מורכב ממבנה אחד ובו ארבע כניסות וארבע קומות, בכל קומה 7 דירות ובסך הכל 28 דירות.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבעים הם בעלי הדירה הרשומה כחלקת משנה 15, אשר שטחה 65 מ"ר, ולהם 1/28 חלקים ברכוש המשותף (להלן: "דירת הנתבעים").
3. לבית קיים תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום ביום 14.11.82 (ת/11). התקנון המוסכם נוגע אך לחלוקת הרכוש המשותף ונקבע בו כי שיעורו של הרכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיה 1/28. משעה שהתקנון המוסכם אינו קובע הוראות בנוגע לאופן ניהול ואחזקת הבית המשותף, הרי שמעבר לחלוקת הרכוש המשותף כאמור בו, חלות על הבית המשותף הוראות התקנון המצוי (ראה גם סעיף 64 לחוק).

עיקרי טענות התובעת

4. התובעת טוענת כי הנתבע 1 כיהן בעבר כחבר נציגות ומאז לא מסר את ספרי הנציגות, דפי החשבון וקופת הנציגות בה החזיק.
5. נטען כי הנתבעים לא שילמו מיסי ועד בית מחודש ספטמבר 2008 ועד מאי 2010, ובסך הכל חובם לנציגות עומד על **1,470 ₪**.
6. עוד טוענת התובעת כי הנתבע השתלט ובנה על רכוש משותף ללא הסכמת בעלי הדירות: בנה מרפסת תוך השתלטות על חלק מה חצר המשותפת, הניח בחלק מה חצר עציצים גדולים המונעים את כניסת יתר הדיירים ל חצר, השתלט על חלק מהמקלט וצרף אותו לדירתו, והוא אף נוהג לאחסן חפצים במקלט ומסרב לפנותם.
7. לטענת התובעת, עת שימש הנתבע 1 כראש הנציגות הוא פירק את האסלה, הברז, הכיור והשיש במקלט וכן פירק את דלת המקלט וכל זאת ל לא החלטת האסיפה הכללית כנדרש. הנציגות טוענת כי עלות השבת המצב לקדמותו הנה **8,027 ₪**.
8. כן נטען כי כשהיה הנתבע 1 חבר נציגות הוא רכש מכספי הנציגות מכסחת דשא, קפיץ לפתיחת סתימות, כלי עבודה וגינון ואף אותם לא העביר לנציגות בתום כהונתו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

9. כמו כן טוענת התובעת כי הנ תבע עושה בשביל הגישה לבניין שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף , לצרכי חנייה.

01. הסעדים המבוקשים בכתב התביעה הנם :

" ליתן צו המורה לנתבעים ו/או למי מהם ו/או מטעמם, להשיב מצב לקדמותו כדלקמן :

- הסרת הבנייה וסילוק יד מהרכוש המשותף.
- השבת מצב לקדמותו במקלט תוך פיקוח הנדסי או לחלופין לשלם 8,027 ₪.
- פינוי החפצים מהמקלט.
- מסירת דו"חות, דפי חשבון וספרי הנציגות לתובעת.
- החזרת כל הכלים אשר נקנו על ידי הנציגות ובפרט מכסחת דשא, קפיץ לפתיחת סתימות, כלי עבודה וגינון או לחלופין לשלם 3,000 ₪.
- פינוי העציצים מהגינה המשותפת.
- לשלם את מיסי הועד והוצאות פינוי חפצים מהמקלט בסך 1,670 ₪"

טענות הנתבעים

11. הנתבעים הכחישו בכתב הגנתם את היותה של התובעת נציגות הבית המשותף . נטען כי מדובר בתביעה אישית, טורדנית וקנטרנית.

21. הנתבעים טענו כי הנתבע 1 פנה לאגודה לתרבות הדיור על מנת להעביר בצורה נאותה ומסודרת את ספרי הנציגות אך לא זכה למענה בעניין . הנתבע מדגיש בהקשר זה כי שימש כנציגות הבית המשותף במשך 8 שנים "ודאג לשמור כל פיסת נייר הנוגעת לנציגות הבית המשותף בתקופתו".

31. באשר לחוב הנטען לנציגות , טוענים הנתבעים כי ביקשו להעביר המחאות לגברת נחמה נזרי על סך דמי ועד הבית, אולם זו בחרה לקרוע אותן , תוך שהיא מבהירה כי יש לשלם במזומן ואין ל ועד הבית חשבון בנק. הנתבע טוען כי על פי הוראות התקנון המצוי , חובה על הנציגות להפקיד את דמי ועד הבית בחשבון בנק על שם הבית המשותף. ביחס לדמי ועד הבית נטען בכתב ההגנה כי עומדת לנתבעים טענת קיזוז "מול גברת נחמה נזרי וגברת חייט". טענת הקיזוז הורחבה במהלך ההליכים גם כנגד דיירים אחרים בבית.

41. הנתבעים מכחישים כי השתלטו על חצר המשותפת, וביחס לבניית המרפסת שם טוענים כי אין מדובר במרפסת אלא ב "ריצוף פינה קטנה מאוד של הגינה בפתח היציאה האחורית " של דירתם. עוד נטען כי החצר היא חלק מרכוש הבית המשותף של בניין מספר 7 ועל כן אין לנציגות הבית מעמד לגביו. כך נטען



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

גם כי "סביר להניח שהשכנים לא התנגדו בשעתו לריצוף" וכי "לאור השהות בהגשת התביעה שנעשתה רק לאחר שש שנים מאז רוצפה כניסת הבית האחורית של הנתב עים ניתן ללמוד כי נתנו השכנים את הסכמתם". עוד טוענים הנתבעים כי אין בריצוף כוונת השתלטות או הסגת גבול. ביחס לעצמים נטען כי הם אך מייפים את החצר המשותפת.

51. באשר לטענה כי צירפו לדירתם שטח מהמקלט, טוענים הנתבעים כי טענה זו לא הוכחה.

61. עוד מכחישים הנתבעים כי הם מאחסנים בחלק מהמקלט חפצים. לטענתם, אין המקלט משמש או ראוי לשמש כמקלט וכי לאורך כל השנים שימש הוא כמחסן עבור כלל הדיירים בבניין. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי יש בסמיכות לבניין מקלט ציבורי גדול שאותו פיקוד העורף מיעדים לחירום. יחד עם זאת, מבהירים הנתבעים בס יכומיהם כי "נכון להיום אין לנתבעים חפצים במקלט כלל ואף הסכים הנתבע ליתן לתובעת את מפתחות החדרון במקלט...".

71. בסיכומיהם, הנתבעים אינם מכחישים כי ביצעו עבודות של פירוק הבנוי במקלט. אלא שלדידם, הם אלו שהתקינו מלכתחילה את הכלים הסניטאריים והדלת במקלט עת שיפצו את דירתם. לדבריהם, בעקבות תלונת השכנים, נערך ביקור של גורם מטעם העירייה אשר הורה להם לפרק ולהחזיר את המצב לקדמותו. אל נוכח הוראה זו, כך לטענתם, פירקו את הכלים הסניטאריים והדלת שהתקינו בעבר במקלט.

81. בסיכומי התביעה עלתה לראשונה טענה הנוגעת להשתלטות על "החלל" אשר נוצר בקומת דירת הנתבעים, בעקבות תוספת הבניה לבניין שבוצעה לפני כשלושים שנה. במענה לכך טענו הנתבעים כי רכשו את הדירה מקודמיהם באופן בו היא בנויה, וכי לא בנו בעצמם כל תוספת לדירה על חשבון הרכוש המשותף. לחלופין נטען כי ככל שקיימת השתלטות כאמור, הרי שהיא נעשתה לפני למעלה מ-30 שנה ולא על ידי הנתבעים. לשיטתם, חוסר המעש במשך עשרות שנים אלו, כמו גם היעדר מחאה, מלמדים על הסכמתם המלאה של יתר בעלי הדירות.

91. ביחס למכסחת הדשא, קפיץ לפתיחת סתימות, וכלי העבודה והגינן טען הנתבע כי רכש אותם מכספו הפרטי.

02. הנתבעים טוענים כי אינם עושים שימוש בשביל הגישה לבית לצרכי חנייה וכי לעיתים ילדיהם, הסרים לבקרים, מחנים שם את אופנועם באופן ארעי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ההליכים שקדמו למתן פסק הדין

12. בפתח הדברים יצוין כי נושא מינוי הנציגות בא על פתרונו לאחר שבהתאם להחלטת כבוד המפקח פנחס לוי מיום 15.11.01, כונסה אסיפה כללית של בעלי הדירות ובה נבחרה הגב' נחמה נזרי לשמש כנציגות הבית המשותף (ראה פרוטוקול הדיון מיום 24.2.11).
22. יצוין עוד, כי באותה החלטה, ולאחר מתן ההוראות באשר לכינוסה של אסיפה כללית, קבע כב' המפקח לוי כי:
- " על הנתבעים, מיד לאחר האסיפה הנ"ל ובחירת הנציגות באותה אסיפה, לשלם לאלתר לנציגות את חובם החל מחודש 9/08 ועד היום.**
- כמו כן, על הנתבעים למסור לידי הנציגות שתיבחר באותה אסיפה, את כל המסמכים שבידיהם הנוגעים לניהולו של הבית המשותף, ובכלל זה דו"חות ומאזנים, קבלות וכיוצב' "**
32. בסיכומיהם, אישרו הנתבעים כי לאחר מתן החלטת כב' המפקח לוי לעיל פתחה הנציגות הנבחרת חשבון בנק. אי לכך, טענו הנתבעים כי העבירו את מלוא חובם לנציגות. דא עקא, כי לטענת הנתבעים הם קיזזו מסכום החוב סך של 1,050 ₪, חוב שנוצר לקופה, לטענתם, עקב אי תשלום מיסי ועד הבית של משפחות חייט, נזרי וסלומון.
42. למרבה הצער, למרות ההחלטה לעיל, הרי שמלבד למינוי נציגות, כל יתר המחלוקות לא באו על פתרון. לפיכך התקיים הליך של הוכחות והבאת ראיות. עדי הצדדים נשמעו בימים 5.6.11 ו- 6.6.11. סיכומי התובעת הוגשו ביום 10.7.11 וסיכומי הנתבעים ביום 25.9.11.

גדר המחלוקת

52. מה דינם של המסמכים המצויים בידי הנתבע 1 והנוגעים לניהולו של הבית המשותף? האם חבים הנתבעים כספים לנציגות ומה גובה החוב, ככל שקיים? האם קיזוז סכום החוב הנטען נעשה כדין? האם עושה הנתבע שימוש ייחודי ברכוש המשותף או בחלקו, ובכלל זה בחצר ובמקלט? האם מכסחת הדשא, הקפיץ לפתיחת סתימות, וכלי העבודה והגינון הנם רכוש הפרטי של הנתבע 1 או שמא נקנו בכספי הנציגות ואזי מדובר ברכוש משותף? האם ביצעו הנתבעים שינויים ברכוש המשותף- עבודות בנייה ופירוק ללא הסכמת בעלי הדירות כנדרש? האם עושים הנתבעים שימוש בלתי סביר במעבר המשותף, לרבות חניית אופנוע עליו?
62. להלן, אדון בכל אחת מהמחלוקות אשר התגלעו בין הצדדים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

א. המסמכים הנוגעים לניהולו של הבית המשותף

72. הנתבע 1 טען בעדותו כי מילא אחר החלטת כב' המפקח לוי והעביר את כל החומר שהיה ברשותו לגב' נזרי, אולם הודה כי השאיר את הספר בו ניהל את ההכנסות ברשותו שכן לטענתו "זה ספר פרטי שלי לצרכי ביקורת" (ראה פרוטוקול 6.6, עמ' 6, שורות 20-25).
82. הגב' נזרי ציינה בחקירתה כי קיבלה את מסמך נ' 1/ וכן- "מעט קבלות ואת חשבונות החשמל". אני קיבלתי גם ספרי קבלות". (פרוטוקול 5.6, עמ' 6 שורה 29).
92. משעה שנבחרה נציגות כדין, הרי שעל הנתבע להעביר לידיה את מלוא המסמכים, וזאת כאמור בהחלטת כב' המפקח לוי. לא מקובלת עלי טענת הנתבע 1 כי ספר ההכנסות הוא "ספר פרטי שלו". אין חולק כי מתועדות בו הכנסות הבית המשותף ומדובר בספר אותו ניהל הנתבע 1 בכובעו כחבר נציגות. בנסיבות אלו הרי שעליו למסור גם את ספר זה לנציגות הנבחרת וזאת בנוסף לכל מסמך וחומר אחר המצוי בידיו והנוגע לניהולו של הבית המשותף.

ב. חוב הנתבעים לנציגות

03. למעשה, המחלוקת בה יש להכריע בשלב זה היא האם מלוא חוב הנתבעים לנציגות שולם, ומה דינה של טענת הקיזוז שהעלו הנתבעים.
13. בכתב התביעה, אשר הוגש ביום 1.8.10, נתבע מהנתבעים סכום של 1,470 ₪ ביחס לחודשים ספטמבר 2008-מאי 2010, סה"כ 21 חודשים, 70 ₪ לחודש. בהחלטת כבוד המפקח לוי מיום 15.11.10 נקבע כי על הנתבעים לשאת במלוא חובם עד ליום מתן ההחלטה. מדברי ב"כ התובעת בדיון שנערך ביום 24.2.11, עלה כי הנתבעים שילמו סך של 750 ₪, כאשר לטענתם, קיזוז ממנו סך של 1050 ₪, אשר לדידם חבה להם הנציגות (ראה נ/1 ונ/2). על כן, לשיטת הנתבעים, פרעו את מלוא החוב.
23. למעשה, הנתבעים הודו בחוב בסך 1,800 ₪, אולם טענת ההגנה שלהם היא זכאותם לקיזוז 1050 ₪ מסכום החוב, עקב תשלומים בהם נשאו באופן אישי על חשבון בעלי דירות אחרים, בעת ששימש הנתבע 1 כנציגות.

33. מקור החוב לתשלומי הנציגות, הנו בסעיף 58 לחוק המקרקעין הקובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

כל הדירות שבבית המשותף , זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה , לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

43. טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי . אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ים ככל שהדין המהותי אינו מעניק להם זכות קיזוז (ראה : י. זוסמן **סדרי הדין האזרחי** (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 **גרינשפון נ' שכטר** פ"ד מ"ט (1) 843), שכן זכות הקיזוז מצריכה הוראה מיוחדת בחוק . חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים ד . נן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים , למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. גם הוראות התקנון המצוי אינן מקימות זכות קיזוז.
53. יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. די בכך להביא לדחיית הגנת הנתבעים וקבלת התביעה בעניין זה.
63. למעלה מן הצורך אציין כי אף אם יש ממש בטענות הנתבעים לגופן, ואינני נדרשת לכך לאור העדר זכות קיזוז כאמור, הרי שהנתבעים פנו אל הנציגות בבקשה לקזז את הוצאותיהם רק לאחר שכבר שילמו מכספם על הוצאות הבית ולאחר הגשת כתב התביעה . הנתבעים בחרו שלא לנקוט בכל הליך משפטי כנגד הנציגות, ובאמצעותו לחייבה בהשבת הכספים, והחליטו להפסיק לשלם את תשלומי הנציגות, בבחינת סעד עצמי. התנהלות זו עומדת בסתירה לחובתו של בעל הדירה לשאת בתשלומים המגיעים ממנו, אף אם יש לו השגות ביחס לתשלום (ראה : ע"א (ת"א) 204/79, **וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף** , פ"מ התשמ"ד א' 498)
73. בעל דירה הטוען כנגד החיוב הנדרש ממנו איננו יכול להימנע באופן חד צדדי מתשלום ועליו לפנות לאסיפה הכללית לקבלת החלטה בעניינו או למצער להגיש תביעה משפטית כנגד הנציגות (ראה : רע"א 294/87, **שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף** (פורסם ב"נבו"), ע"א 3454/04 (מחוזי- ת"א) **אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ** (טרם פורסם)). הדברים נכונים גם לגבי בעל דירה הטוען ליזכותו להשבת כספים שהוציא מכספו הפרטי לצר כי החזקת הרכוש המשותף, עת שימש כנציגות, כפי שטוען הנתבע 1 בהליך דנן.
83. לפיכך, ושעה שהנתבעים מודים בחובם וטענת ההגנה שלהם נשענת על זכותם לקיזוז בלבד , הרי שאני מקבלת את התביעה בעניין זה ומורה לנתבעים לשלם סך של 1,050 ₪ לנציגות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. האם עושה הנתבע שימוש ייחודי ברכוש המשותף או בחלקו?

93. הנתבעים, כאמור, טוענים לעשיית שימוש ייחודי והשתלטות על הרכוש המשותף בכמה מוקדים בבית המשותף- השתלטות על החצר המשותפת, צירוף שטח מהמקלט לדירת הנתבעים ואחסון חפצים במקלט ללא קבלת הסכמות יתר בעלי הדירות, וכן חניית אופנוע בשביל המעבר.
04. כבר עתה אציין כי טענת הנתבעים להרחבת הדירה תוך השתלטות על רכוש משותף וזאת על ידי **סגירת החלל בחלקו האחורי של הבניין**, הנה טענה שעלתה לראשונה בסיכומים ולא עלתה כלל בכתב התביעה. משלא הועלו הטענות העובדתיות בכתב התביעה ולא התבקש כל סעד פרטני בנושא זה ו בשים לב כי הטענה עלתה לראשונה בסיכומים, לא מצאתי מקום לדון בה. ברי, כי בעניין זה שמורות לתובעת טענותיה, וזאת במסגרת ההליכים המתאימים.

שימוש ברכוש המשותף – מסגרת נורמטיבית

14. הלכה היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות "שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. בע"א 549/73, **אנטוני ו- הלן וינטרס נ' אלוני זמורה ו- 3 אח'**, פ"ד כח (1), 645. נקבע כי "שימוש סביר" הוא שימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים. עוד נקבע כי את השימוש יש לבחון לפי "תנאי המקום והזמן" (ראה גם: ע"א 708/72 **פרשק נ' רוזנברג ואח'**, פ"ד כח 817,824-825).
24. סעיף 31 (א) לחוק קובע כי: "**באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים- (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר.**"
34. בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי נקבע כי: "**החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.**"
44. בפסיקה נקבע מבחן ה-**שלילה התמידית** של החזקה ברכוש המשותף, לאמור **אם אכן נשללה החזקה ברכוש המשותף**, באופן שאינו ארעי, נדרשת לכך הסכמת בעלי כל הדירות (ראה: ע"א 429/80 **גורפינקל נ' ארליך**, פ"ד לו 141, ע"א 93/81, **אליאס נ' שיפר**, פ"ד לו 444).
54. במסגרת תיקון מספר 18 לחוק, קבע המחוקק חריג **באשר להרחבת דירה**. במקרה כזה, הרי שעל אף השלילה התמידית של החזקה ברכוש המשותף, די יהיה ברוב הקבוע בסעיף 71 לחוק:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותי הם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוים ימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

64. נפנה, אם כן, לבחינת נסיבות המקרה דן.

שימוש ייחודי ובנייה בחצר המשותפת

74. מהתמונות שהוצגו בפני (ת/13) ומביקורי במקום עולה כי חלק מגינת הבית המשותף הוגבה כך שיהווה המשך ישיר לכניסה האחורית לדירת הנתבעים וכן רוצף במרצפות.

84. טענת הנתבעים לפיה מדובר בחצר השייכת לבניין מספר 7 ולא לבית המשותף, אין לה כל בסיס. מתשריט הבית המשותף עולה בבירור כי מדובר בקרקע המהווה חלק מ הבית המשותף. בביקור שערכתי במקום טענו הנתבעים כי דיירי בניין מספר 7 הם אשר "מטפחים את המקום", אולם וודאי שאין בכך בכדי להקנות להם זכויות קנייניות בשטח זה.

94. בעדותה, העידה הגב' נחמה נזרי, בעלת דירה בבית ומי ששימשה כנציגות בעבר, (להלן: "ניזרי") על הבנייה שבוצעה, לשיטתה, בחצר המשותפת:

" על הגינה המשותפת בנו הנתבעים מרפסת. היה במקום דשא והם יצקו רצפת בטון וריצפו אותה. בנו עמודים ועליהם התקינו גגון, וכל זה בשטח שהוא בהמשך לחלל של המקלט שסופח לדירתם..." (ראה בפרוטוקול הדיון מיום 5.6.11, עמ' 4, שורות 34-32).

05. מר יצחק חייט, אשר העיד כי משנת 1967 הוא בעל דירה בבית (להלן: "חייט"), אמר בעניין זה כי – **" קודמיהם עשו הרחבה בדירתם. הם עשו מרפסת אבל לא סגרו אותה. העמודים נבנו עבור תוספת הבנייה לדיירים. הם לא נבנו על ידי הנתבעים" (פרוטוקול 5.6, עמ' 12 שורות 9-7).**

15. יפה מזרחי, בעלת דירה בבית ועדה מטעם התביעה, העידה כי כל אחד יכול לעשות שימוש בשטח החצר. עם זאת, היא אישרה בחקירתה הנגדית כי הנתבעים הם אלה שריצפו את השטח המצוי בכניסה לדירתם: "...הנתבעים לא בנו ולא סגרו מרפסת. יש שטח מרוצף ביציאה מדירת הנתבעים. הם ריצפו את השטח הזה..." (פרוטוקול 5.6, עמ' 8, שורות 22-20) ולגבי המצב המתועד בתמונה (ת/1) אמרה הגב' מזרחי- " זה המצב מאז שהנתבעים באו לדירה. אולי יש שינוי קטן במשטח המרוצף..." (עמ' 9 שורות 27-26).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

25. הנתבעים עצמם הודו בסיכומיהם כי הריצוף נעשה **על ידם** שש שנים קודם לכן (ראה סעיף 25 לסיכומים- "לאור השהות בהגשת תביעה בעניין הריצוף **שנעשתה רק לאחר כ- 6 שנים מאז רוצפה כניסת הבית האחורית**..." (ההדגשה שלי- י.ע.ש). ויובהר כי כעולה מעדות הנתבע 1, הוא גר בבית קרוב ל-25 שנה (ראה פרוטוקול 6.6, עמ' 1, שורה 37).
35. מחומר הראיות שהונח בפני ומביקור שערכתי במקום התרשמתי כי הבניה על גבי החצר המשותפת מהווה **שימוש ייחודי** ברכוש המשותף, אשר יש בו כדי לשלול באופן תמידי את החזקה ברכוש המשותף. מדובר בהגבהה מבטון של מפלס החצר עד למפלס הכניסה האחורית לדירת הנתבעים, וריצופו (להלן: "**המרפסת**"). המרפסת מהווה, למעשה, המשך ישיר לדירת הנתבעים, באופן בו דלת חדר השינה צמודה אל המרפסת וממנה ניתן להגיע אל יתר שטח החצר המשותפת. כאמור, הבנייה ממוקמת בכניסה **לחדר השינה** של הנתבעים, ומהווה חוצץ בין חדר השינה לבין שאר החצר. בנייה זו, כמתואר לעיל, מהווה חלק אינטגרלי מדירת הנתבעים באופן בו מובן מאליה כי יתר בעלי הדירות הבית המשותף לא יעשו בה שימוש דומה. אין זה סביר כי בעלי דירות אחרים ירדו מביתם לשבת במרפסת הממוקמת בצמידות לחדר השינה של הנתבעים כאשר בינה לבין חדר השינה שלהם מפרידה אך דלת. אף מהעדויות שנשמעו בפני עלה כי בפועל בעלי הדירות האחרים אינם עושים שימוש במרפסת זו.
45. מביקורי במקום התרשמתי כי כל עוד לא תוסר ההגבהה והריצוף, תימשך החזקה הייחודית באותו חלק ברכוש המשותף, אשר כאמור, בשל אופיו ומיקומו, יתר בעלי הדירות לא יעשו בו שימוש כלשהו.
55. הנתבעים לא הביאו כל תימוכין להסכמה נוהגת, אף לא כזו שהיו שותפים לה רוב בעלי הדירות. למעשה, מלבד לטענה בעלמא לא הציגו הנ תבעים לכך כל ראיה, וודאי שלא הראו התנהגות ברורה וחד משמעית המלמדת על הסכמה וגמירות דעת של בעלי הדירות או חלקם (ראה: ע"א 7388/97 **עזבון משה שמיר ז"ל נ. יעל דולב (שמיר)** פ"ד נה 690). עשיית שימוש ייחודי אף בחלקו של הרכוש המשותף, מצריכה את קבלת ההסכמות כנדרש על פי דין- ואלו לא הוצגו בפני.
65. לפיכך, אני מורה לנתבעים להסיר את הבנייה בכניסה האחורית לדירתם, לרבות הגבהה הבטון והריצוף וכן יתר חפציהם האישיים המצויים שם.
75. כאמור, נטען גם כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי בשטח החצר המשותפת, הקרוב למרפסת שבנו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

85. בביקור במקום התרשמתי כי מדובר בחצר רחבה , אשר חלקה אכן מצוי בסמיכות לכניסה האחורית לדירת הנתבעים. מעבר לבניית המרפסת לא הבחנתי בסממנים כלשהם של השתלטות הנתבעים על החצר.

95. בביקורי במקום הבחנתי כי על אף שיש בעצמים שהציבו הנתבעים בחצר כדי להוות מעין "חוצץ" בין החצר הסמוכה אליהם ליתר חלקי החצר , הרי שהם אינם מהווים מחסום או גדר של ממש . כל המעוניין להיכנס לשטח החצר הסמוך אל דירת הנתבעים יכול לעשות זאת . על כן , לא מצאתי כי יש להורות על הסרת העצמים או הזזתם ממקומם.

שימוש ייחודי במקלט או חלקו

06. הנתבעים לא הכחישו כי הם עשו שימוש במקלט לצרכי אחסון חפצים . בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי חדרון אחד משטח המקלט , והמצוי בסמוך לדירת הנתבעים , נסגר בדלת ברזל . בעת ביקורי במקום , החדרון היה ריק אולם התובעת טענה כי פינוי החפצים ממנו נעשה רק בסמוך לביקור.

16. בין הצדדים התגלע ויכוח האם אחסון החפצים נעשה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 27.6.07, כנטען על ידי הנתבעים ועולה מפרוטוקול האסיפה הכללית - ת/19, או שמא חתימות הדיירים על ת/19 מזויפות, כנטען על ידי התובעת. לא מצאתי צורך להכריע בשאלה, שכן בסיכומיהם טענו הנתבעים כי נכון לעת כתיבת הסיכומים אין להם חפצים במקלט כלל ואף כי הם נכונים ליתן לתובעת את מפתחות החדרון במקלט, אותו סגרו באמצעות דלת שהתקינו.

26. בשים לב להסכמתם של הנתבעים להוצאת חפציהם ולמתן מפתח המקלט לנציגות , הרי שככל שעוד נותר בכך צורך , אני מורה כי על הנתבעים להסיר חפציהם מהמקלט וליתן לנציגות את מפתח דלת חדרון המקלט. הנציגות, כמו גם יתר בעלי הדירות בבית המשותף , יוכלו לעשות שימוש בחדרון זה **ולא תהא לנתבעים כל חזקה ייחודית בו והם לא יוכלו לעשות בו כל שימוש ייחודי.**

36. אעיר עוד שהטענה כי עלות פינוי החפצים מהמקלט עלתה לנציגות 200 ₪ - לא הוכחה. למרות שנזרי טענה בעדותה כי "התיעוד על תשלום סכום זה מופיע בדו"ח של ועד הבית לחודש 8/09" (ראה בפרוטוקול 5.6, עמ' 5 שורה 3), מועד בו גב' חייט שימשה ב ועד הבית (ועל כן אין מדובר בדו"ח המצוי בידי הנתבע), לא הוצג לי דו"ח זה או כל קבלה אחרת שיש בה כדי להעיד על התשלום.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ד. ביצוע עבודות בנייה או פירוק במקלט

פירוק דלת המקלט

46. בנוגע לפירוק דלתות המקלט העיד חייט כך- "הייתי בועד הבית עד לפני 5 שנים... החליף אותי הנתבע ...1 אחרי שעזבתי את ועד הבית, הוציא הנתבע 1 את הדלתות, סגר את הפתחים של המקלט וזהו. אני לא יודע יותר כלום... דלת המקלט המקורית הייתה עם רשת לאוורור. הנתבע מס' 1 הוציא אותה ושם במקומה דלת אחרת מברזל אטומה לגמרי. גם את פתחי האוורור של המקלט הוא אטם. היו 6 פתחים בערך" (פרוטוקול 5.6, עמ' 10 שורות 25-38).

56. נזרי העידה לגבי דלת המקלט כי: "בתוך המקלט יש חדרון קטן המשמש לשירותים ולמטבחון ושם יש דלת. את הדלת הפנימית הזו נעלו הנתבעים. היום יש מנעול על הדלת הזו מזה כ-3 חודשים, מנעול שהותקן ע"י הנתבעים. כיום הדלת הזו נעולה ע"י הנתבעים ואין דלת חיצונית למקלט שכן היא הוסרה על ידי הנתבעים... לפני כן, במקור הייתה דלת ברזל מסו רגת למקלט, דלת מברזל שמאפשרת כניסת אוויר למקלט..." (פרוטוקול 5.6, עמ' 3 שורות 4-14).

... "אני טוענת שהייתה במקור דלת מתכת עם סורגים במקלט שהוחלפה בדלת אחרת בידי הנתבעים. אני ראייתי את הדלת המקורית. אני מדברת על הדלת חזית המקלט ולא על הדלת הפנימית של החדרון. הנתבעים התקינו במקום הדלת המקורית דלת ברזל אטומה". (פרוטוקול 5.6, עמ' 9, שורה 28-30).

66. הגב' יפה מזרחי, שגם היא בעלת דירה בבית ולפי עדותה גרה שם למעלה מ-30 שנה, העידה מטעם הנתבעים (להלן: "מזרחי"). מזרחי אמרה בעדותה כי: "לא הייתה דלת במקלט, והנתבעים הם שהתקינו אותה מיוזמתם, ואף אחד לא שילם להם כסף" (פרוטוקול 6.6, עמ' 9 שורה 5).

76. מצאתי את עדותם של נזרי וחייט בעניין זה משכנעת יותר. שניהם העידו על דבר קיומה במקור של דלת בכניסה למקלט, אשר הוסרה על ידי הנתבעים. גם בתמונות שהוצגו בפני (ת/8) ובביקורי במקום, בולט לעין כי קיים משקוף בכניסה למקלט אולם הדלת שהייתה בו הוסרה. לא מצאתי לנכון לקבל את הטענה לפיה מעולם לא הייתה דלת כניסה למקלט. יתרה מכך, מת/8 ובביקורי במקום עלה בבירור כי חלף אותה דלת בכניסה למקלט שהוסרה הותקנה דלת ברזל הסוגרת את אחד מחדרונות המקלט. התמונות ומראה העיניים עולים בקנה אחד עם טענות התובעת בעניין זה. מקובלת עלי גם הטענה כי הנתבעים הם שהסירו את הדלת, שכן טענה זו אף מתיישבת עם הודאת הנתבעת 2 בחקירתה- "אנחנו פירקנו את דלת המקלט שכן היא הייתה שייכת לנו ואנחנו פירקנו אותה" (פרוטוקול 6.6, עמ' 7 שורה 25), כמו גם עם היעדר הכחשת הנתבעים להתקנת דלת חלופית לאחד מחדרונות המקלט.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

86. לפיכך, אני מורה לנתבעים להתקין את הדלת שהוסרה או לחלופין להתקין דלת חלופית בכניסה למרתף. טיבה של הדלת שתותקן יי קבע באסיפה הכללית, אולם עלותה לא תעלה על 1,500 ₪. סכום זה קבועתי על דרך האומדנה, כאשר לקחתי בחשבון את הצעת המחיר שצירפה התובעת לתביעתה (נספח ב'), בעוד שהנתבעים לא הציגו כל הצעת מחיר חלופית.

פירוק האסלה, הברז, הכיור והשיש

96. בחקירתו הנגדית של חייט הוא העיד על דבר קיומם של שירותים, מטבחון וכיור במקלט, עוד מעת סיום בניית הבית - "כשאני קניתי את דירתי המקלט בבית שימש כמקלט. היו בפנים שירותים, מטבחון, כיור והכל. כמו בכל מקלט. ככה קיבלנו את המקלט" (פרוטוקול 5.6 עמ' 11 שורות 13-14) ... "אין לי מושג שעיריית ירושלים ביקשה לפרק את הכלים הנ"ל. זה לא נכון" (שם, שורה 16).

07. הנתבע 1 טען כי "לא היו מעולם במקלט כלים סניטריים... לא היו במקלט לא שירותים ולא דלתות. אני שיפצתי לפני שנים את הדירה שלי ובאותו זמן התקנתי במקלט אסלה שתשמש אותי עד לגמר השיפוצים בדירה. לאחר שהתלוננו ע לי הדיירים בעירייה ודרשו ממני להשיב את המצב במקלט לקדמותו, דיברתי עם המפקח בעירייה שהורה להשיב את המצב לקדמותו כפי שהיה".

17. מזרחי אמרה בעדותה כי: "לא היו קיימים אף פעם במקלט אסלה, כיור או ברז. הנתבעים הם שהתקינו אותם במקלט לפני הרבה שנים. במשך השנים ביקש ו מהנתבעים לסלק את האסלה בגלל המטרד שנגרם ממנו. הנתבעים לא ביקשו כסף עבור התקנת הציוד הזה במקלט" (פרוטוקול 6.6, עמ' 9 שורות 1-3).

27. התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה, להוכיח כי במקלט היו במקור שירותים, אסלה, ברז, כיור ושיש. לא מן הנמנע כי הנתבע הוא שהתקין כל ים אלה בעת ששיפץ את דירתו ולאחר מכן הסיר אותם בעקבות תלונות השכנים, כפי שטען. מכל מקום, התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי הנתבע ים פרקו והרסו רכוש משותף ולפיכך אין לי אלא לדחות טענה זו.

ה. מכסחת דשא, קפיץ לפתיחת סתימות, כלי עבודה וגינון

37. התובעת ביקשה להפוך את נטל השכנוע ולהעבירו לכתפי הנתבע ים, שכן לטענתה הנתבע 1 לא העביר את כל המסמכים שיש בידיו והנוגעים לפועלה של הנציגות לידי ה (וזאת לאחר שחדל לשמש כנציגות ובניגוד להחלטתו של כבוד המפקח לוי כאמור לעיל). לטענת התובעת, במצב דברים זה אין בידיה האפשרות להוכיח טענתה כי מדובר ברכוש אשר נקנה בכספי הנציגות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

47. בפסיקה נקבע כי יש להפעיל את דוקטרינת הנזק הראייתי (ראה: בע"א 361/00, **עאזם ד'אהרן נ' סרן יואב**, פ"ד נט(4), 310), רק מקום בו אין לתובע כל אפשרות להוכיח טענתו בדרך אחרת. בע"א 9936/07 **מאיה בן דוד נ' ד"ר אייל ענתבי** נאמר כי:

"לצורך העברת הנטל לפי דוקטרינת הנזק הראייתי, נדרש כי התרשלותו של הנתבע תשלול מן התובע את האפשרות להוכיח אחד או יותר ממרכיבי עילת התביעה. מקום בו חרף התרשלותו של הנתבע, עומדת לתובע האפשרות להוכיח את תביעתו - אין תחולה לדוקטרינת הנזק הראייתי (ראו: ע"א 9328/02 מאיר נ' לאור, פ"ד נח(5) 54, 64 (2004); ע"א 754/05 לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק, פס" 9 לפסק-הדין (פורסם בנבו), 5.6.2007; ע"א 679/08 סנפרוסט בע"מ נ' מוסכי צמח בע"מ, פס" 27 לפסק-הדין (פורסם בנבו), 2.1.2011).

57. במקרה זה אני סבורה כי הייתה לתובעת אפשרות להוכיח כי מכסחת הדשא, הקפיץ לפתיחת הסתימות וכלי העבודה והגינון, או אפילו חלקם, נרכשו מכספי הנציגות. ראשית, נזרי הודתה בחקירתה כי קיבלה מידי הנתבע 1 מסמכים שונים ובהם **"ספרי קבלות"** (עמ' 6 שורה 29). יחד עם זאת לא הוצגו קבלות התומכות בטענת התובעת. כמו כן, נזרי ציינה בעדותה כי **"יש עדים שיכולים להעיד שהמכסחת והקפיץ נרכשו מכספי הדיירים"** (פרוטוקול 5.6, עמ' 6, שורה 38), אולם- עדים כאלו לא הובאו לעדות מטעם התובעת. מעדותו של חייט עלה כי כלל אין בידיו כל מידע בדבר אותו ציוד- **"אין לי מושג לגבי מכסחת דשא. אני לא זוכר שביקשו ממני לרכוש מכסחת דשא"** (פרוטוקול 5.6, עמ' 10, שורה 30). לגבי כלי העבודה והגינון לא נשמעה כל עדות ולא הוצגה כל ראיה.

67. לפיכך אין מקום להעביר את נטל השכנוע לעניין זה, ויש לבוחנו מתוך ההנחה שנטל זה מוטל על התובעת (ראה: ע"א 548/78, **שרון נ' לוי**, פ"ד, ל"ה(1), 736, ע"א 2275/96, **לימה נ' רוזנברג**, פ"ד מז(2), 605). התובעת לא הביאה ראיות להוכחת טענותיה.

77. בנסיבות אלו, משלא הוכחה התובעת טענותיה אלו ולא הביאה את הראיות לשם ביסוסן, אין לי אלא לדחותן.

ו. חנייה במעבר המשותף

87. הנתבע 1 העיד בעניין זה כך- **"לי אין אופנוע. האופנוע שייך לילדים שלי. מדי פעם הם באים לוקחים דברים מהבית והם נוסעים. הילדים לא גרים אצלי בבית. יש דייר בבית שיש לו קטנוע והוא זה שחונה בשביל כפי שנראה בתמונה המוגשת בזה ומסומנת (נ/11). לא ידוע לי על פנייה שנעשתה אליו מ ועד הבית. שמו ברק א קראי..."** (התובעת לא התייחסה לטענה זו של הנתבע 1 ואף לא זימנה את אותו ברק אקראי כעד הזמה).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

97. לא מצאתי כי התובעת הוכיחה שהנתבעים מבצעים שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף לצורך חנייה. אף אם הנתבעים או באי ביתם מחנים מדי פעם אופנוע במעבר המשותף, כנטען, הרי שמביקורי במקום התרשמתי כי מדובר במעבר רחב ועל כן שימוש זה לא מונע או מפריע למעבר הבאים והשבים. כך גם לא נמנעת מבעלי דירות אחרים היכולת להחנות את אופנועיהם שם באופן ארעי. משכך, מצאתי כי מדובר בשימוש סביר ועל כן אני דוחה את הטענה בעניין זה.

ז. סוף דבר

- א. הנתבעים יעבירו לידי התובעת לאלתר את מלוא המסמכים, לרבות ספר ההכנסות, וזאת כאמור בהחלטת כב' המפקח לוי מיום 15.11.10.
- ב. הנתבעים ישלמו לתובעת את חובם בסך 1,050 ₪. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
- ג. הנתבעים יסירו את הבנייה בכניסה האחורית לדירתם לרבות הבטון והריצוף וכן יסירו את יתר חפציהם האישיים המצויים שם.
- ד. על הנתבעים להסיר חפציהם מהמקלט וליתן לנציגות את מפתח דלת חדרון המקלט הנציגות, כמו גם יתר בעלי הדירות בבית המשותף, יוכלו לעשות שימוש בחדרון מקלט זה ולא תהא לנתבעים כל חזקה ייחודית בו, או בשטח אחר מהמקלט.
- ה. הנתבעים יתקינו את הדלת שהוסרה מהכניסה למקלט או לחלופין יתקינו דלת חלופית בכניסה למקלט. טיבה של הדלת שתותקן ייקבע באסיפה הכללית, אולם עלותה לא תעלה על 1,500 ₪.
- ו. שאר הסעדים המבוקשים - נדחים.

היות וחלק מהתביעה התקבל וחלקה האחר נדחה - ישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ג, 29 נובמבר 2012, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום המקרקעין